

1501160-87.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501160-87.2021.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232447/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 19862903 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 1949/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2232447 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO VILA DA SILVA

1º Juiz(a) de Direito Auxiliar: Dr(a). FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Vistos.

DANILO VILA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na figura típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante disposta no artigo 61 inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto, segundo narra a denúncia, no dia 25 de agosto de 2021,

por volta das 16h29, na Rua José Lencione, nº 270, Bairro Fundação Manoel Guedes, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, guardava e mantinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 28 (vinte e oito) porções de crack, subproduto da droga cocaína, com peso bruto aproximado de 5,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da importância de R\$ 5,00 (cinco reais) em dinheiro.

O réu foi notificado (fl. 104) e apresentou defesa prévia às fls. 110/112.

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022 (fls. 113/115) e o réu foi citado (fl. 126).

Durante a audiência colheu-se o depoimento das testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução processual, as partes ofertaram suas alegações finais orais (fls. 131/137).

Os autos vieram para a conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tramita em desfavor de DANILO VILA DA SILVA, o qual, segundo consta da peça inicial acusatória, transgrediu o preceito primário da norma penal incriminadora inserida no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante disposta no artigo 61 inciso II, alínea "j", do Código Penal.

De início, afasta-se a tese preliminar ofertada em alegações finais acerca da ilegalidade da prisão do acusado.

A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, mesmo que não inserida no rol das suas atribuições constitucionais, constituiu ato legal.

Não se ignora que, na hipótese dos autos, os guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina e, em dado momento, deliberaram pela abordagem do réu, pessoa já conhecida nos meios policiais, enquanto estava em local de intensa e frequente venda de drogas.

Na ocasião, lograram apreender com o acusado as porções de droga destinadas à venda, caracterizando, portanto, a infração penal.

Logo, percebe-se que os guardas não realizaram investigações prévias, mas apenas surpreenderam o acusado praticando atos ilícitos.

Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição a guardas municipais de procederem à prisão.

Nesse sentido:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática de tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal). 2. Recurso improvido." (STJ, RHC 20.714/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, DJ 4/8/08) - destaquei.

"HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. (...) 6. Habeas corpus não conhecido." (HC 426.969/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) - destaquei.

Ademais, eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não enseja nulidade da ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítimo todo o procedimento.

Portanto, fica afastada qualquer eventual nulidade pela atuação dos guardas civis municipais.

Superada a tese preliminar invocada, cotejadas as provas colhidas nesta ação penal, os fatos descritos na denúncia foram cabalmente demonstrados, impondo-se o acolhimento da pretensão punitiva com a condenação do acusado.

Deveras, sabe-se que é necessário, para toda e qualquer condenação, que exista juízo exauriente acerca da autoria e materialidade delitiva.

A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência de fls. 08/09, auto de exibição e apreensão de fl. 11, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 12, laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 77/79, comprovante de depósito judicial de fl. 86 e pela prova oral colhida.

De igual modo, a autoria é incontestada.

Feitas as considerações iniciais, passo à análise das provas colhidas nos autos, notadamente as que foram produzidas em audiência.

Durante a instrução, a testemunha VANESSA ROCHA SERAFIM, guarda civil municipal, indagada pela Acusação, narrou que na data dos fatos sua equipe efetuava patrulhamento pelas ruas do Bairro Fundação Manoel Guedes, local conhecido pelo intenso comércio ilícito de drogas. Ao passarem pela Rua José Lencione, avistaram o acusado que, ao notar a aproximação da viatura, repentinamente mudou seu comportamento e dispensou um objeto no local antes de ser abordado. O parceiro da depoente encontrou em poder do réu a quantia de cinco reais, enquanto ela localizou o objeto dispensado e constatou tratar-se de dois kits de porções de crack. Indagado, Danilo prontamente assumiu a propriedade das drogas e confirmou sua atuação na mercancia ilícita. O réu informou ter adquirido os kits de uma mulher desconhecida, venderia cada porção pelo valor de dez reais e que seu turno acabava de se iniciar. O acusado mencionou que praticava a venda de drogas há duas semanas. A depoente informou ainda já ter abordado o acusado em outras ocasiões, porém somente havia encontrado com ele quantias em dinheiro. Todas as abordagens se davam por conta de denúncias envolvendo o réu e sempre eram realizadas em locais conhecidos pela venda de drogas. Não havia nenhum petrecho para o consumo das drogas apreendidas com o acusado. Às indagações da Defesa destacou que não havia outras pessoas no local e foi possível observar que o réu dispensou as porções de drogas.

O guarda civil municipal DANIEL ADRIANO VIEIRA ratificou na íntegra o depoimento de sua parceira Vanessa Rocha Serafim.

Por sua vez, perante a Autoridade Policial, o réu DANILO VILA DA SILVA permaneceu em silêncio (termo de interrogatório de fl. 05). Durante seu interrogatório judicial, ouvido sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa, disse que apenas possui uma passagem pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional. Residia na Cidade de São Paulo e mudou-se para o Município de Tatuí há cinco ou seis meses. Veio para a Cidade para morar com sua mãe e trabalhar na empresa "Zanchetta". Por não conseguir o emprego, sua genitora o despejou. Atualmente está empregado e reside com seu encarregado. Quanto aos fatos, contou que na data de sua prisão apenas confessou possuir seis porções de crack e uma porção de maconha, bem como a quantia de cinco reais. Ao ser agraciado com a liberdade provisória, soube que os agentes públicos atribuiriam para ele mais dois kits de drogas para ser preso. Após alguns dias, recebeu a notificação com cópia da denúncia indicando que com ele teriam sido apreendidas vinte e oito porções de crack. Destacou que não estava com nenhuma sacola e as drogas que possuía estavam em sua boca. Ao ser agredido pelo GCM, cuspiu as porções no chão. Não estava vendendo drogas no local. Apenas confessou que vendia drogas por medo dos guardas civis municipais. As drogas que com ele estavam eram destinadas ao seu consumo e foram adquiridas com o dinheiro que recebeu de sua mãe antes de ser por ela despejado.

Os depoimentos e o interrogatório foram captados por meio de sistema audiovisual, nos termos do Provimento CGJ 08/2011 e das Leis nº 11.419/06 e 11.719/08, e através de videoconferência, mediante utilização do aplicativo Teams/Microsoft, com a disponibilização da mídia em pasta digital, em decorrência da pandemia do Covid-19

(Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020.

Pois bem. Finalizada a instrução, diferentemente do quanto aduzido pela Defesa, o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu é responsável pela prática do delito a ele atribuído na denúncia; a assertiva é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito.

As porções de drogas encontradas em poder do acusado, as circunstâncias da prisão em flagrante e as declarações dos guardas civis municipais evidenciam a finalidade de tráfico.

A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu.

Vale citar: "Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288).

Ainda, importante destacar que a lei pune o tráfico ilícito de drogas em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, as condutas descritas na denúncia, quais sejam de "guardar" e "manter em depósito", sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito.

Cabe também mencionar que nenhuma restrição merece os depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pela abordagem e prisão do acusado, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada acerca de suas condutas. Nesse sentido:

"... nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória." (Ap.Crim. 103.701 TJSP);

"... a simples condição de policial não torna a testemunha suspeita ou impedida" (STF - RT 68/64);

"... não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

O quadro probatório é, pois, eficaz e conclusivo em relação à materialidade e autoria dos fatos narrados.

A negativa do réu no tocante à mercancia ilícita não merece prosperar, porquanto dissociada dos demais elementos de informação colhidos, de modo que não se presta a influir no convencimento deste magistrado.

Neste aspecto, importante consignar que o réu sequer ofertou versão coerente acerca da forma como conseguiu adquirir as drogas que apontou ser destinadas ao seu consumo. Isso porque, no início de seu interrogatório confirmou que estava desempregado e sua genitora o havia expulsado de casa por não trabalhar.

Posteriormente, disse que sua mãe foi quem lhe deu o dinheiro por ele utilizado para adquirir as porções de drogas.

Também não é demais lembrar que o réu mencionou que foram apreendidas em seu poder seis porções de crack e uma porção de maconha. No entanto, não houve a apreensão da apontada porção de maconha, mas vinte e oito porções de crack, todas elas embaladas

de forma idêntica, consoante fotografias de fls. 19 e 21.

Além disso, devem prevalecer os depoimentos dos agentes de segurança, os quais foram claros, congruentes e verossímeis, bem como possuem correlação com a narrativa exposta na denúncia.

Não é crível entender que, no exercício de suas funções, guardas civis municipais atuem com a intenção deliberada e desarrazoada de incriminar pessoas pela prática de ilícitos dos quais não são responsáveis. Inclusive, revela-se totalmente desarrazoado que para tanto se valham de porções de drogas não apreendidas durante a abordagem para atribuí-las ao acusado.

De se ver que os agentes públicos responsáveis pela diligência asseveraram com clareza terem avistado o acusado que, ao notar a presença da viatura, mudou de comportamento e dispensou algo ao chão. Ainda, destacaram que logo após a dispensa do objeto pelo réu, procederam à sua abordagem, constatando que o material consistia nas porções de drogas apreendidas.

As testemunhas também destacaram que o réu confessou a venda de drogas no local, dando detalhes acerca do preço de cada porção e o horário no qual efetuava a mercancia ilícita.

Não bastasse, embora o silêncio na fase inquisitorial consista em um direito do acusado, causa estranheza o fato de não ter ao menos informado na Delegacia de Polícia quais as drogas encontradas em seu poder e que elas eram destinadas ao seu consumo de forma exclusiva, tal qual por ele alegado em Juízo.

Com base em tais elementos, indene de dúvidas que a versão do acusado é pueril e inverossímil e visa unicamente acobertar sua atuação na venda de drogas.

Convém lembrar não ser preciso para a caracterização da narcotraficância que o agente seja surpreendido no exato momento em que fornece materialmente a droga a terceira pessoa, bastando circunstâncias seguras de que para tanto se destina o tóxico com ele encontrado. Este é o caso dos autos em atenção aos elementos de informação aqui coligidos.

De igual modo, não comporta acolhimento a tese exposta em autodefesa no sentido de que as drogas seriam destinadas ao consumo do acusado, porquanto nenhum elemento de informação foi apresentado a fim de fomentar a sua alegada condição de usuário.

De se ver que a quantidade de drogas apreendida não se coaduna com a mera posse para consumo do agente.

Não fosse isso, é indene de dúvidas que muitos usuários entram no tráfico para custear a compra de drogas para uso próprio (a denominada figura do “traficante-usuário”), situação que, por si só, não afasta a ilicitude do fato.

Em suma, a Defesa não logrou trazer aos autos nenhum elemento que fosse capaz de, ao menos, colocar em dúvida algum ponto do acervo probatório constituído nestes autos, o qual se revela farto e demonstra com riqueza de detalhes toda a ação delituosa. Os argumentos expostos em sede de memorial não possuem força bastante para infirmar os argumentos fáticos e jurídicos veiculados na denúncia.

Inconteste, pois, a ocorrência de todos os elementos típicos, subjetivos e objetivos, necessários para a responsabilização do réu pela prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira etapa, atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, inexistente circunstância judicial negativa a influir em desfavor do acusado. Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber: 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

A quantidade e natureza da droga apreendida serão consideradas na terceira etapa da dosimetria da pena, notadamente para a análise da fração adequada para a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes.

Ressalvado o entendimento até então adotado por este Juízo em relação à circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (crime praticado em período de calamidade pública), a partir desta decisão passo a adequar-me à orientação recorrente provinda das Cortes Superiores no tocante à natureza subjetiva da referida agravante.

Neste sentido, confira-se:

"Não é possível aumentar a pena pelo crime de tráfico de drogas em razão da situação de pandemia da Covid-19. Isso porque o crime, em si, não está diretamente relacionado a essa circunstância de calamidade em questão, situação diferente de quando um delito é praticado durante um incêndio, naufrágio ou inundação." (STJ - HC 660.930/SP; 6ª Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julgamento: 14.09.2021).

"Em relação à agravante prevista no art. 61, I, "j", do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva." (STJ - AgRg no HC 677.124/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julgamento: 03.08.2021).

"Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico." (STJ - AgRg no HC 669.508/SP; 6ª Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julgamento: 15.06.2021).

De igual modo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada - Afastamento da agravante da calamidade pública - Ausência de nexo causal - Regime prisional fechado mantido - Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501003-51.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal;

Relator(a): Desembargador(a) Jucimara Esther de Lima Bueno; Origem: Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 15.02.2022).

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 47,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 21,5 GRAMAS DE MACONHA - MERCANCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO CORRETA, POIS LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE. Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501141-18.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Willian Campos; Origem: Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 01.09.2021).

"Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo. Preliminar. Inépcia da denúncia - ausência dos requisitos previstos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal; Mérito. Exclusão de culpabilidade - réu que praticou o delito sob coação moral irresistível; Pleito subsidiário: incidência do redutor previsto pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Requerimento da concessão do direito de recorrer em liberdade e dos benefícios da justiça gratuita. Pedido de restituição do veículo apreendido. 1. Concessão da justiça gratuita. Presunção de veracidade das alegações de insuficiência de recursos financeiros. Artigo 99, parágrafo 3º, do CPC. 2.

Preliminar. Inépcia da denúncia. Peça acusatória que preencheu, rigorosamente, os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, possibilitando, dessa forma, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 4. Dosimetria da pena que comporta reparos.

Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos que permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de ¼. Afastamento da circunstância agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal. Estado de emergência sanitária que não facilitou a execução da conduta delituosa.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que qualificada, com

redução da pena em 1/6. Súmula n. 545 do STJ. Quantidade expressiva de maconha - 30 Kg. Circunstâncias do fato que permitem concluir que o acusado participa de organização criminosa e se dedica à prática de atividades ilícitas o que impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. 5. Manutenção do regime inicial fechado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incabível. 6. Veículo modificado especialmente para o transporte de drogas. Existência de compartimentos secretos. Restituição inviável. 7. Manutenção da prisão preventiva. Motivos que levaram a decretação da prisão e sua manutenção que permanecem inalterados. Gravidade concreta dos fatos. Expressiva quantidade de drogas e transporte interestadual que apontam para certo grau de estrutura ilícita. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501692-95.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Marcos Alexandre Coelho Zilli; Origem: Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 08.06.2021 e 09.06.2021).

O réu faz jus à circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, tendo em vista sua menoridade relativa. No entanto, deixo de sopesá-la, porquanto nesta etapa a pena não pode ficar aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ), motivo pelo qual a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.

Por outro lado, concedo a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, devido à primariedade do acusado e a ausência de elementos que indiquem fazer parte de organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas.

Importante destacar que este Juízo entende que a existência de passagens pela Vara da Infância e Juventude, apesar de não gerar maus antecedentes ou reincidência, consiste em elemento apto e suficiente para afastar a incidência do tráfico privilegiado, pois denota que a conduta do acusado tem sido permeada pela prática de atos antissociais.

A situação retratada nos autos é peculiar, porquanto a certidão de fl. 26 denota a distribuição do Processo nº 1506087-86.2019.8.26.0015 em desfavor do réu. No entanto, em pesquisa realizada por este Juízo vê-se que ele foi agraciado com a remissão cumulada com advertência.

Neste viés, nos termos do artigo 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente, "a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação".

Em suma, a remissão é concedida, como forma de exclusão do processo ou, ainda, quando iniciado o procedimento importa na sua suspensão ou extinção, de modo que não gera antecedentes e sequer há a imposição de medida socioeducativa, razão pela qual não se revela suficiente o apontamento acima indicado para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No tocante à fração a ser adotada, reduzo a pena em 1/3 (um terço), gerando a reprimenda legal de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena.

Anoto que não é cabível redução maior em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, a saber: 28 (vinte e oito) porções de crack, subproduto da cocaína, com peso líquido de 4,61 gramas; as quais devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

De fato, embora em quantidade não expressiva, o crack possui efeitos deletérios àqueles que dele fazem uso com alta probabilidade de dependência imediata e catastrófica após a sua ingestão, bem como se apresenta extremamente nocivo à sociedade como um todo, tornando-se um problema endêmico de saúde pública em todo o território nacional.

Por isso, entendo que a fração adotada revela-se condizente e justa em consonância com a sua reprovação social.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E BENESSES LEGAIS.

Atentando-se à primariedade do acusado, considerando, ainda, que "Não se considera

hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006." (§ 5º ao artigo 112, da lei 7.210/1984 – LEP, incluído pela Lei nº 13.964/2019), bem como o entendimento pacificado nas Cortes Superiores, FIXO O REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c" do Código Penal.

Ainda, em atenção ao entendimento firmado no HC nº 596.603/SP do E. STJ, reputo presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de modo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em: I) prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de execução criminal; e II) limitação de fim de semana.

Diante da substituição operada, não há que se falar em suspensão condicional da pena.

Atento ao regime de cumprimento e a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, bem como a sua substituição por penas restritivas de direito, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a imposição da custódia preventiva. De fato, não há nos autos elementos seguros a indicar que o réu, de alguma forma, possa trazer risco à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal ou, ainda, que vá se furtar da aplicação da lei penal. Deste quadro, DEFIRO o recurso em liberdade.

Ausentes nos autos informações acerca da situação econômica do réu, ESTABELEÇO o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia para CONDENAR o réu DANILO VILA DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de multa de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa aplicada, em entidade a ser designada pelo juízo da Execução Criminal e limitação de fim de semana.

CONFORME FUNDAMENTADO, DEFIRO O APELO EM LIBERDADE.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, caso tal medida ainda não tenha sido providenciada.

DECLARO o perdimento do numerário apreendido, qual seja a quantia de R\$ 5,00 (auto de exibição e apreensão de fl. 11 e comprovante de depósito judicial de fl. 86), em favor da União, para ser revertido diretamente ao Funad, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal c.c. o artigo 63 e parágrafos, da Lei nº 11.343/06.

O réu está assistido por Defensora nomeada, circunstância que deixa presumir que não dispõe de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, incabível se mostra a condenação ao pagamento das custas.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à Advogada nomeada para patrocinar os interesses do réu (fl. 105), nos termos do Convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente e demais comunicações necessárias.

P.I.C.

Tatui, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA